

1501730-69.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO CALVERT

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... influência direta do local da prática do tráfico de drogas.

A lei prevê a causa de aumento de pena em caso de o tráfico ser praticado "nas imediações" desses locais, não especificando uma distância objetiva. Deve o julgador aplicar a causa de aumento sempre que a atividade de mercancia de drogas tiver influência direta sobre tais locais, pretendendo atingir seus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501730-69.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501730-69.2020.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafaela Esteffany Costa da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO CALVERT

Vistos.

Rafaela Esteffany Costa da Silva, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 28 de agosto de 2020, por volta da 17hs30min, na rua Manoel Fernandes, nº 864, Jundiapéba, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para a entrega e consumo de terceiros, as drogas descritas no auto de exibição e apreensão de folhas 17-18 e no laudo pericial de folhas 111-113, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (folhas 86-88).

Recebida a denúncia (folhas 89-90), a ré foi citada (folha 289) e apresentou resposta à acusação por meio de defensor público (folha 298).

Em audiência de instrução, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas de acusação, passando-se, por fim, ao interrogatório da ré. Durante a audiência de instrução, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da exordial (folhas 315-320). A Defesa, por sua vez, requereu preliminarmente o reconhecimento da ilegalidade da atuação dos Guardas Municipais e a ilicitude das provas correlatas; requereu, no mérito, a absolvição da ré, pela insuficiência do conjunto probatório ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06 ou a fixação da pena em seu patamar mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (folhas 324-335).

É o relatório. Fundamento e decido.

Preliminarmente, não vislumbro qualquer ilegalidade na atuação dos guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante da ré. Conforme se extrai do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer cidadão pode realizar a prisão de quem se encontra em situação de flagrante delito. O Tribunal de Justiça de São Paulo vem rejeitando o reconhecimento da nulidade ventilada pela Defesa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Alegação de nulidade em virtude de prisão realizada por guardas municipais – Inocorrência, diante da inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão em flagrante por qualquer pessoa e, evidentemente, ainda, a apreensão de coisas, objeto do crime – Ausência de insurgência quanto a autoria e materialidade delitivas, sendo referidas matérias, portanto, incontestas e irrecorríveis – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o recorrente é reincidente, razão pela qual há expresso veto legal à sua concessão – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado e com a reincidência do apelante – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o montante da pena imposta – Inviabilidade de aplicação do instituto da detração – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500560-79.2021.8.26.0599; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capivari - 2ª Vara; Data do Julgamento: 13/01/2022; Data de Registro: 13/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo drogas variadas para imediata distribuição – Depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela diligência – Validade – Pena alterada – Reconhecida a atenuante da confissão e compensada, nos termos do artigo 67, do Código Penal, com a agravante da reincidência – Redutor negado, mercê da comprovada reincidência – Regime mantido por conta da reincidência e da gravidade concreta da conduta – Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500220-45.2021.8.26.0435; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pedreira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022)

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (folhas 12-16), pelo auto de exibição e apreensão (folhas 17-18) e pelo laudo do exame químico toxicológico (folhas 111-113), com resultado positivo para “tetrahidrocannabinol – THC” (“maconha”), “crack” e cocaína.

A quantidade de drogas encontrada, consistente no peso líquido de 84,5 gramas de “maconha”, 2,94 gramas de “crack” e 16,6 gramas de cocaína, a forma de armazenamento e as circunstâncias do caso concreto indicam que se destinava ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros, tipificando o crime previsto no

artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A autoria também é certa e deve ser imputada à ré, diante dos elementos dos autos, notadamente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ouvida em juízo, a ré negou a posse das drogas apreendidas. Disse que é usuária de drogas e que havia acabado de comprar 3 (três) porções de cocaína, quando foi abordada por dois policiais à paisana, os quais apontaram a arma para a ré e a renderam. Disse que o traficante de drogas fugiu do local. Esses policiais chamaram os guardas municipais que realizaram a prisão. Disse que as drogas foram encontradas “no meio do mato” pelos guardas municipais. Confirmou que assumiu a posse das drogas e a venda de entorpecentes para os guardas municipais, mas somente porque ficou com medo dos policiais em razão do “tom” em que falavam.

Não obstante a negativa da ré, os demais elementos dos autos são bastante claros acerca da autoria.

Com efeito, a testemunha Edson Marcos da Cruz, guarda municipal, ouvido em juízo, informou que, em patrulhamento com seus colegas próximo a uma escola municipal, receberam denúncia de transeuntes apontando que uma pessoa com as características da ré estaria vendendo entorpecentes em uma rua adjacente; ao se aproximarem da ré, esta tentou empreender fuga, mas foi apanhada e, ao ser abordada, foi encontrada a droga dentro de uma sacola que estava com a ré. A ré também trazia consigo dinheiro trocado, mas quem encontrou foi sua parceira. A ré afirmou que era o primeiro dia dela vendendo drogas no local.

A testemunha Ana Claudia Vicentino, guarda municipal, ouvida em juízo, confirmaram a versão dos fatos narrada acima. Disse que realizavam patrulhamento em uma escola em patrulhamento e, ao abordar alguns indivíduos, estes denunciaram que uma “moça” estava realizando venda de drogas numa rua adjacente. Dirigiram-se ao local e abordaram a ré, a qual carregava consigo uma sacola com as drogas apreendidas; disse que com a ré também foi encontrado dinheiro trocado, mas não se lembra exatamente onde estava o dinheiro. A ré disse que era o seu primeiro dia vendendo drogas.

Os depoimentos de guardas municipais, policiais militares ou policiais civis, na condição de testemunhas, devem ser considerados idôneos. Não se concebe que os agentes, sem razão aparente, pretendessem incriminar inocentes desconhecidos, de forma tão abjeta. A ilação dos agentes foi corroborada, por sinal, pela eloquente apreensão das porções de entorpecente.

Ao contrário: são testemunhas que depõem compromissadas, com presunção de veracidade por serem funcionários públicos, narrando sobre atos que, de ofício, foram praticados no exercício de suas funções.

Nesse sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência”. (Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 73.518, relator Ministro Celso de Mello, julgado em 26.3.1996)

"PROVA - Depoimento de policial - Valor: Não demonstrando a defesa, como lhe incumbe à luz da regra do artigo 156 do CPP, os motivos que teria o policial para, ciente da inocência do acusado, imputar-lhe falsamente a prática de crime, seu depoimento, firme e coerente naquilo que é essencial, deve ser prestigiado em detrimento da palavra do réu, principalmente quando este apresentar personalidade voltada para a prática de ilícitos penais". (Tribunal de Alçada Criminal, apelação 1.442.515/4, relator Desembargador Xavier de Souza, julgada em 29.6.2004)

Outrossim, impossível a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, sob a argumentação de que as drogas não se destinavam à entrega a terceiros, mas sim ao consumo próprio, uma vez que não está em conformidade com os elementos probatórios colhidos dos autos.

As circunstâncias do caso concreto impedem que seja acolhida a tese da desclassificação. A quantidade e qualidade de drogas encontrada, e seu acondicionamento em pequenas porções, não se coaduna com o uso por apenas uma pessoa em curto espaço de tempo, levando à conclusão de que estava efetivamente vendendo drogas.

Desta feita, a condenação da ré pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é de rigor.

Será aplicável, no entanto, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isso porque a ré é primária e não há qualquer elemento de prova que indique que, à época dos fatos tratados no presente processo, a ré dedicava-se a atividades criminosas.

Ademais, a quantidade de drogas apreendida e as circunstâncias do caso concreto não permitem enquadrar a ré como grande traficante ou como detentora de uma rede organizada de venda de drogas, assemelhando-se ao pequeno traficante, premido pelo vício em entorpecentes ou pelas circunstâncias sociais, a quem a lei pretendeu beneficiar pela causa de diminuição de pena em relevo.

Por fim, entendo que não se aplica a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06.

Isso porque, muito embora o local em que foram apreendidas as drogas se encontrasse a uma distância que varia entre 10 (dez) e 250 (duzentos e cinquenta) metros das entidades apontadas pelo Ministério Público, o "croqui" não demonstra que as entidades não se encontram num espectro de influência direta do local da prática do tráfico de drogas.

A lei prevê a causa de aumento de pena em caso de o tráfico ser praticado "nas imediações" desses locais, não especificando uma distância objetiva. Deve o julgador aplicar a causa de aumento sempre que a atividade de mercancia de drogas tiver influência direta sobre tais locais, pretendendo atingir seus frequentadores ou efetivamente o fazendo, o que não está demonstrado nos autos.

Em relação especificamente à "Creche Nossa Senhora do Carmo", consta de pesquisas realizadas por este magistrado que o local se encontra "temporariamente fechado", não sendo possível afirmar que se encontrava em funcionamento na data dos fatos, especialmente diante da situação de pandemia.

Passo à dosimetria da pena, o que faço nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e dando preponderância à natureza e à quantidade da substância, à personalidade e à conduta social do agente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, pondero que a qualidade da droga apreendida deve ser considerada

para o recrudesimento da pena-base.

Com efeito, o artigo 42 da Lei 11.343/06 determina que seja considerada a qualidade da droga para fins de estabelecimento da pena-base na primeira fase da dosimetria. Esta determinação legal, aliada à grande elasticidade do preceito secundário do tipo criminoso do artigo 33, caput, desta lei, indica que o juiz deverá aplicar penas diferentes para os diferentes tipos de substâncias entorpecentes, de acordo com a lesividade da droga.

No sentido de apenarem-se de forma diferenciada os traficantes de acordo com a quantidade e a qualidade da droga comercializada, dando efetividade ao princípio da individualização da pena, já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"A despeito do sustentado pela defesa, o magistrado de primeiro grau fundamentou exaustivamente a fixação da pena base do réu acima do mínimo legal, pautando-se no art. 42 da Lei 11.343/06, observando a quantidade e natureza da droga, bem como a conduta social do acusado. Tais circunstâncias extrapolam o já previsto pelo tipo e devem ser consideradas pelo magistrado quando da fixação das penas, como disposto no supramencionado artigo, pois no presente caso extrapolam o já previsto pelo tipo.

Assim, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo.

Repise-se, o art. 42 da Lei 11.343/06 é expresso ao determinar que a quantidade e a natureza do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena base". (apelação 0001695-14.2013.8.26.0396, relatada pelo Desembargador Edison Brandão, julgada em 9.9.2014, extraído do voto relator)

No caso dos autos, com a ré foram apreendidas porções de "crack", droga que pode, sem qualquer receio de erro, ser apontada como a mais lesiva entre todas aquelas que são comumente comercializadas pelos traficantes, a qual determina grave dependência física e psicológica, afeta de forma agressiva o sistema nervoso central e acarreta em graves sequelas pessoais aos usuários, determinado comportamentos agressivos e antissociais por parte do usuário, de forma a causar danos pessoais, sociais e familiares graves e perenes.

Impossível apenar da mesma forma o agente que vende "crack" e aquele que vende outras drogas de potencial lesivo reconhecidamente menor.

Desta forma, em atenção à qualidade da droga comercializada pelo réu, recrudesço sua pena-base em 2 (dois) anos, a qual fixo em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, reconheço a presença da circunstância atenuante consistente na menoridade relativa da ré, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, e reduzo a pena em 1/6 (um sexto), a qual passa a ser de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, considerando a primariedade da ré, a ausência de antecedentes criminais e a ausência de comprovação de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar de 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 3 (três) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 390 (trezentos e noventa) dias-multa.

Utilizo este patamar mediano, uma vez que, no caso dos autos, com a ré foram apreendidas porções de três drogas diferentes, quais sejam, de "maconha", "crack" e cocaína, tendo em conta, outrossim, que o "crack" pode, sem qualquer receio de erro, ser apontado como a mais lesiva entre todas aquelas que são comumente comercializadas pelos traficantes, a qual determina grave dependência física e psicológica, afeta de forma agressiva o sistema nervoso central e acarreta graves

sequelas pessoais aos usuários, determinado comportamentos agressivos e antissociais por parte do usuário, de forma a causar danos pessoais, sociais e familiares graves e perenes.

À mingua de outras causas modificativas, torno definitiva as penas fixadas acima.

A pena pecuniária será calculada no patamar mínimo legal, ante a ausência de dados sobre a capacidade financeira da ré.

A pena privativa de liberdade imposta à ré deverá ser cumprida em regime inicial aberto, tendo em vista a quantidade da pena imposta e a sua primariedade, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a imposição de regime inicial fechado prevista no artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade será substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, na forma dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reclusão, e limitação de fim de semana, com indicação de tratamento de conscientização e desintoxicação para dependentes de drogas, nos termos do artigo 48, parágrafo único, do Código Penal e artigo 47 da Lei 11.343/06.

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade da ré, bem como os motivos e as circunstâncias do delito indicam que a substituição é suficiente para o cumprimento das finalidades da persecução criminal, ressalvando-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade da substituição, quando presentes os requisitos legais, não obstante a vedação do artigo 44 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar Rafaela Esteffany Costa da Silva, qualificada nos autos, às penas de 3 (três) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 390 (trezentos e noventa) dias-multa, calculada no patamar mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade será substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, na forma dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reclusão, e limitação de fim de semana, com indicação de tratamento de conscientização e desintoxicação para dependentes de drogas, nos termos do artigo 48, parágrafo único, do Código Penal e artigo 47 da Lei 11.343/06.

A ré poderá interpor recurso de apelação em liberdade, tendo em vista a aplicação de penas não privativas de liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03, condeno, ainda, a ré, ao pagamento das custas judiciais, no valor de 100 (cem) Ufesps.

Publique-se. Intimem-se.

Mogi das Cruzes, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA